

1500186-45.2019.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... não foi inquirida.

A propósito:

Tráfico - envio de pacote com drogas para penitenciária - não comprovação de que mandado pela ré, insuficiente para tanto o fato de figurar como remetente - caracterização de responsabilidade objetiva - absolvição por falta de provas
Tráfico - encomenda não recebida pelo acusado preso - conduta atípica - mera solicitação de envio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1500186-45.2019.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500186-45.2019.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2200427/2019 - DEL.POL.PONTAL, 3825430 - DEL.POL.PONTAL, 431/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2200427 - DEL.POL.PONTAL, 431/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2200427 - DEL.POL.PONTAL, 431/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2200427 - DEL.POL.PONTAL, 431/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2200427 - DEL.POL.PONTAL, 431/19/414 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN MAX COSTA PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou KELVIN MAX COSTA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que, em data incerta, porém no ano de 2019, no Centro de Detenção Provisória de Pontal, situado na Rodovia Armando Sales de Oliveira KM 349, nesta comarca de Pontal, o acusado prestou auxílio a pessoa não identificada, a fim

de remeter uma porção de maconha, com peso líquido de 14,540g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial fls. 01/132, conduzido pela autoridade competente.

Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fls. 155/159).

Decisão de fl. 169/171 afastou as preliminares e recebeu a denúncia em 08 de março de 2022.

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogado o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela improcedência e absolvição. Alegou tratar-se de crime impossível, vez que a pessoa responsável por remeter o pacote deveria ser responsabilizada penalmente, visto que o réu não tinha conhecimento acerca do envio da droga. Diz que deve ser reconhecida a impropriedade do objeto, tendo em vista que o pacote sequer chegou a ser entregue ao réu. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a figura do privilégio, com redução no patamar máximo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminares.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), documento (fls. 10/16), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 08/09).

Contudo, não há comprovação suficiente da autoria.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Eleudes Aparecido Pozzetti Junior, agente penitenciário, compromissado; que se recorda dos fatos; no dia, estava trabalhando; a sala era pequena; outro agente avistou uma coisa estranha no sapato e me chamou pra conferirmos juntos; Kevin assumiu a propriedade da droga e disse que tinha emprestado o nome da irmã para outro preso enviar drogas pra ele (Kevin); o réu não teve contato com a droga; a sala de revista tem uma grade e ele ficou do lado de fora; ele não teve a posse da encomenda em nenhum momento; ela veio do correio e a gente fez a revista de um lado da grade.

William Zerbiti Choji, agente penitenciário, eu me recordo; a droga veio pelo Sedex em nome de Kerolim Éster; veio no solado do tênis e vimos uma substância esverdeada análogo à maconha; o Kelvin disse que a droga era dele, mas a Kerolim não tinha culpa; foi um colega da prisão que enviou a droga.

Kelvin Max Costa Pereira, réu, disse que não tinha ciência dos fatos. Estava trabalhando, quando foi chamado pelos diretores da unidade prisional. Não sabia de nada. Soube que a droga havia chegado ali em nome de sua irmã. Foi forjado. Sua irmã nunca lhe mandou nada via Sedex, apenas pessoalmente. Não sabe para quem era a droga. Confessou os fatos para poder tirar sua irmã da celeuma, pois ficou com medo de prejudica-la, pois ela tem filhos para criar.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Nesse contexto, entendo que a autoria do delito não foi devidamente comprovada.

In casu, à míngua de elementos concretos, não ficou provada a prática de nenhum ato material pelo paciente de auxílio a terceiro com objetivo de tráfico. O fato de ser sua irmã constar como a remetente via correios e a simples suspeita de que ele teria sido o solicitante do entorpecente, o qual teria sido enviado por outro ex-detento, não restaram suficientemente demonstrados. O réu não admitiu os fatos em Juízo, sendo que a remetente não foi inquirida.

A propósito:

Tráfico - envio de pacote com drogas para penitenciária - não comprovação de que mandado pela ré, insuficiente para tanto o fato de figurar como remetente - caracterização de responsabilidade objetiva - absolvição por falta de provas

Tráfico - encomenda não recebida pelo acusado preso - conduta atípica - mera solicitação de envio de entorpecentes não configura crime, nem mesmo tentado, modalidade incompatível com o tráfico - absolvição por atipicidade Recurso do MP

prejudicado (TJSP; Apelação Criminal 1500090-41.2019.8.26.0624; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ENVIO DE DROGAS POR CORREIO. MODALIDADE SEDEX. ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. FALTA DE PROVAS IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO....II - No caso concreto, o paciente foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave de forma objetiva, sem constatação de sua autoria, mesmo que mediata, sob acusação de que teria tentado receber drogas via correio sedex dentro do estabelecimento penitenciário. (...) V - Verifica-se, pois, que o eg. Tribunal, com amparo em mera responsabilidade penal objetiva, sem provas concretas da conduta do paciente, decidiu pelo concurso de agentes, situação que configura constrangimento ilegal, já que, in casu, não houve como se concluir que o paciente praticou a falta grave, pois sequer foi comprovado que manteve contato com o material lhe destinado, nem mesmo que o teria solicitado à pessoa remetente. Habeas Corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para afastar a falta grave homologada e todos os seus consectários, por falta de provas." (Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021, grifou-se).

Ademais, conforme destacado no mencionado acórdão, o fato de "solicitar" a remessa de entorpecente não é previsto como comportamento criminalizado pelo art. 33 da Lei 11.343/06. Mesmo que o acusado tenha efetivamente pedido o envio de maconha a terceiro, sua ação não passou disso, já que a erva, segundo os relatos do acusado e dos agentes penitenciários nunca chegou às mãos do reeducando, sendo apreendida na revista.

Nessa linha, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

"1. Segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Agravado foi ter solicitado à namorada que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou. 2. Com efeito, a tão só ação do Acusado de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impune, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", à qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1795980/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019).

"A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a ocorrência da conduta típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir" que viria, em tese, a ser praticada por este, uma vez que não se comprovou a compra e venda da droga entre o recorrido e o remetente da substância entorpecente" (...) "o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido da impossibilidade da tentativa de tráfico de entorpecentes, pois o tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos se constitui em crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de apenas uma das ações previstas na norma para que se configure o delito de tráfico, ficando assim afastada a possibilidade de tentativa do crime".(AgRg no REsp 1676696/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Tem-se, portanto, que o dolo, elemento subjetivo do tipo penal não foi devidamente comprovado nos autos.

E, não é demais lembrar que "em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extirpa de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (In RT. 708/339).

Conforme Tourinho Filho (RT 619/267), "uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que

intimamente considerem o réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”.

Destarte, diante da inexistência de provas suficientes a demonstrar que o acusado concorreu para a prática do crime, a absolvição é de rigor, mesmo porque milita em favor dele o princípio do in dubio pro reo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra KELVIN MAX COSTA PEREIRA e o ABSOLVO da imputação pelo cometimento do delito descrito na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Pontal, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA